

1500167-18.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500167-18.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500167-18.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008667/2022 - DEL.POL.BERTIOGA, 22371471 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2008667 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NIVAGNER SILVA ARAUJO JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Consta na denúncia que: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de janeiro de 2022, às 21h20, na Rua Aprovada, 611, 328, Chácara Vista Linda, nesta cidade e comarca de Bertioga, NIVAGNER SILVA ARAUJO JUNIOR, qualificado à fl. 11, vendia e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 208 (duzentas e oito) porções de cocaína, pesando 275g (duzentos e setenta e cinco gramas), 167 (cento e sessenta e sete) porções de crack, pesando 40g (quarenta gramas) e 91 (noventa e uma) porções de maconha, pesando 170g (cento e setenta gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, auto de constatação preliminar de fls. 16/17 e fotografia de fls. 13/15. Segundo apurado, nas circunstâncias mencionadas, o denunciado carregava uma sacola nas mãos em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Além disso, recebia uma nota de R\$10,00 (dez reais) de Edgar Sergio da Silva, momento em que foi abordado por Policiais Militares que faziam patrulhamento de rotina pelo local. Durante a revista, constatou-se que o denunciado trazia consigo, no interior da sacola, as drogas mencionadas acima, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, além de R\$262.00 (duzentos e sessenta e dois reais). Nada de ilícito foi encontrado com Edgar, que disse ter ido ao local para comprar drogas. A forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade apreendida e as circunstâncias em que se deu o flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

Efetuada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva do acusado em 11 de janeiro de 2022 (fls. 47/49).

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para o oferecimento de defesa prévia, a qual foi apresentada às fls. 97/100

Pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 133/137.

A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022 (fls. 107/111), ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento.

Em audiência, foram ouvidas testemunhas, bem como interrogado o acusado.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 22/23), pelo auto de constatação preliminar (fl. 20/21) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 92/94).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Sergio Silva de Andrade declarou que: quando adentraram a rua ele tentou sair correndo. Ele estava com uma sacola com drogas na mão. Havia cocaína, maconha e pedra. Avistaram ele com a sacola quando adentraram na via, tendo ele tentado correr para uma viela. Ele falava que não era dele. Também foi encontrado com dinheiro, não se recordando do montante. Ele era conhecido pelos policiais do bairro. Estava em Operação Verão. Ele estava no canto do local de venda. Ele tentou entrar em uma residência. A rua é com saída e atrás de um campo. Ele estava com outro rapaz, que falou que era usuário. Esse rapaz tinha dinheiro e disse que tinha ido comprar a droga. Era pouco dinheiro, coisa de cinco ou sete reais. Nivagner negou o tráfico.

Em seu interrogatório, declarou que: 21 anos. Solteiro. Tem uma filha. Trabalha como ajudante de pedreiro. Estava vendendo droga com outro rapaz. A polícia chegou e o prendeu, juntamente com rapaz. Perguntaram se havia mais drogas, tendo o declarante negado.

Há, portanto, prova robusta para a condenação. Respeitado o entendimento da Defesa, não há falar em insuficiência probatória pelo esquecimento de detalhes acidentais pela testemunha. Inequívoca a presença do réu no local e data dos fatos, bem como o seu flagrante com os entorpecentes. Soma-se a isso a sua confissão.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363.2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminosa, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À

HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

3. O agente que, na qualidade de mula do tráfico, agiu de modo esporádico como transportador da droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do modus operandi da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, independentemente do relato dos policiais quanto à confissão informal, observa-se existirem elementos que, conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, demonstram o envolvimento com a criminalidade. Além da natureza das drogas, observa-se que o acusado foi recentemente condenado por tráfico de drogas (1500751-22.2021.8.26.0536). Não obstante a ausência de trânsito em julgado, tal circunstância, aliada a natureza das drogas, mostra-se suficiente para se demonstrar o envolvimento habitual do réu com a traficância.

Houve, com efeito, intervalo de menos de três meses entre a libertação do réu e sua nova prisão, demonstrando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como afastando a possibilidade de novo beneplácito penal.

A quantidade de drogas (inferior a 500g líquido) não pesa em desfavor do acusado. A natureza destas (cocaína, crack e maconha), por sua vez, demanda repreensão penal mais severa, com modulação do redutor do artigo 33, § 4º do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. demonstra a primariedade técnica. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas serão valoradas na terceira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de invocá-las nesta oportunidade,

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incidentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sendo inviável, porém atenuar a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343.2006, conforme fundamentação retro.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício.

Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o fechado, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR NIVAGNER SILVA ARAUJO JÚNIOR às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Em consulta ao processo 1500751-22.2021.8.26.0536, observo que o réu, após ser condenado como incurso no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, foi beneficiado com alvará de soltura em 20/10/2021. A sua prisão em menos de três meses (10/01/2022) neste processo, portanto, demonstra a insuficiência de medidas em meio aberto, gerando prognóstico negativo em caso de libertação. Há, por consequência, necessidade de se resguardar a ordem pública. Expeça-se guia de execução provisória, recomendando-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II).

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA